

0000084-49.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... penal.

Nesse sentido:

"APELAÇÕES - Tráfico de drogas e Associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006) - (...). Crime de Associação para tráfico - Conjunto probatório frágil - Ausência de elementos suficientes que demonstrem a estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os corréus - Absolvição reconhecida, nos termos do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000084-49.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000084-49.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 326/2021 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAILANE PEREIRA DO NASCIMENTO e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de KAILANE PEREIRA DO NASCIMENTO e BRUNA DOS SANTOS SIQUEIRA, qualificadas nos autos, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos combinados com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, nos termos da inicial acusatória de fls. 123/125.

Oferecida a denúncia, as rés foram notificadas às fls. 143 (Kailane) e 144 (Bruna), apresentando as suas defesas prévias às fls. 154/155 (Bruna) e 182/183 (Kailane). Não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 19/04/2022, com designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 192/195).

Durante a instrução criminal procedeu-se à inquirição das testemunhas e das informantes judiciais, sendo as rés interrogadas, ao final. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, o Ministério Público de forma oral, em audiência (fl. 243), e as defesas na forma de memoriais escritos.

O Parquet pugnou pela parcial procedência da ação penal, com a consequente condenação das rés pelo crime de tráfico de droga, reconhecendo-se a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da mesma Lei quanto à corré Bruna, e a absolvição de ambos pela infração penal remanescente.

A defesa de Bruna acompanhou parcialmente o parecer ministerial. Por conta de sua confissão, requereu a consideração dessa atenuante, assim como da redutora disposta no § 4º do artigo 33, da Lei de Tóxicos, e sua absolvição pelo crime de associação para o tráfico (fls. 244/247).

Por sua vez, a defesa da corré Kailane pugnou pela total improcedência da ação penal, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da figura privilegiada do tipo, assim como a atenuante da menoridade relativa. Por fim, requereu a restituição do dinheiro e do celular apreendidos (fls. 260/261).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva do tráfico de drogas encontra-se cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 04/08), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), fotografias (fls. 50/53), laudo de constatação provisória (fls. 58/60) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 238/240), cujos resultados foram positivos para “cocaína”, substância presente nas listas da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; bem como pelas provas orais.

Com relação à prova de autoria deste mesmo crime (tráfico de drogas), tenho que esta restou igualmente confirmada. Senão vejamos.

O policial militar André Luiz de Jesus da Silva confirmou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que a corré Bruna confessou informalmente que recebeu as drogas de Kailane para guardá-las, dizendo que esta lhe contou que havia pego os entorpecentes com uma pessoa de nome Thiago. Declarou que já havia informações dando conta de que Kailane costumava guardar narcóticos para terceiros. Esclareceu que na data dos fatos Kailane e a adolescente Mariana Carolina estavam em via pública, próxima ao quartel da polícia militar, sendo que, ao sair para patrulhar a cidade, suspeitou do comportamento de ambas. Disse que foram encontrados entorpecentes com a inimputável, e apenas dinheiro com Kailane. Já em diligências no endereço dessa acusada, a corré Bruna, sua vizinha, assustou-se com a chegada das viaturas policiais, correndo para o interior do imóvel, o que despertou a suspeita policial. Asseverou que Bruna, ao ser abordada, confessou de pronto o tráfico, dizendo que havia aceitado guardar os narcóticos pois atravessava dificuldades financeiras. O depoente negou que houvesse informações indicando que ambas estavam associadas para o tráfico.

A informante judicial Tarcisa Pereira Paulino Vicente, avó materna de Kailane, disse que comprou o aparelho celular encontrado na posse de sua neta.

A também informante judicial Nilcelene Pereira Vicente, genitora da acusada Kailane, respondeu que o dinheiro encontrado em sua poder era de origem lícita. Afirmou que sacou a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais) dias antes, e estava usando conforme a necessidade, e que os R\$ 200,00 (duzentos reais), apreendido

pelos agentes da lei com sua filha lhe pertencia.

Bruna em seu interrogatório confessou parcialmente os fatos, negando qualquer associação com Kailane, todavia. Disse que a droga apreendida em sua casa lhe foi entregue por Kailane, sua vizinha para que guardasse, e que esta pegava os entorpecentes "aos poucos". A interroganda declarou que não conhecia a adolescente Mariana Carolina, pois Kailane tinha livre acesso à sua casa para manipular os entorpecentes, antes de entregá-los a terceiros. Disse que dias antes policiais militares estiveram na casa de Kailane, o que fez a ela ficar receosa, por isso, solicitou que a acusada retirasse os entorpecentes de sua casa. Contou que no dia dos fatos, viu Kailane conversando com o proprietário das drogas, e ambos acertando de buscá-las à noite em sua casa. Contudo, já no período vespertino, Kailane foi presa em flagrante juntamente com a adolescente, sendo que em diligências na casa daquela, os policiais militares acabaram chegando até à sua. Bruna disse ter colaborado com os agentes da lei, entregando-lhes os entorpecentes. Afirmou que aquela havia sido a primeira vez que guardava drogas. Esclareceu que Kailane, ao notar sua dificuldade financeira, lhe propôs o vil serviço. Disse que receberia por semana, o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), o que sequer chegou a ocorrer, pois fora presa antes de atingir o lapso temporal.

Por sua vez, Kailane declarou-se inocente. Disse que um "menino" comentou consigo que precisava de alguém para guardar entorpecentes, então, sabendo que Bruna, sua vizinha, precisava de dinheiro, intermediou a vil contratação, que teria ocorrido sem a sua presença. Questionada, disse que não foi presa com a adolescente Mariana Carolina. Disse que estava em frente a sua residência quando os agentes públicos chegaram com a menor, dizendo que esta teria dito que pegara entorpecentes naquele local. De acordo com a interroganda, nada de ilícito foi apreendido em sua residência, apenas o dinheiro e o seu celular. Por fim, disse que não conhecia a adolescente até aquele dia.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a prova aqui formada compromete sobremaneira as duas acusadas, ao menos quanto ao crime de tráfico de drogas.

Destarte, a despeito da confissão de Bruna, à vista do interesse público aqui em jogo, deve ser analisada sua postura frente as demais provas, de modo a verificar se há convergência ou divergência no cotejar de todas elas.

No caso dos autos observo que a confissão judicial se deu livre de vícios e coações, fornecendo elemento seguríssimo de prova para condenação das duas réas, vez que está em linha com a fala do policial militar responsável por suas prisões-captura, conforme se viu acima.

Veja-se a explicação de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

Lado outro, impende salientar a ampla credibilidade que costumo conferir às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, guardas municipais, ou mesmo, qualquer outro agente de segurança pública, seguindo, aliás, a maioria da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim o faço, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que um policial; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso da militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, ele próprio, violá-la, com o fito de incriminar um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só. Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, ou mesmo amizade, hipótese destes autos, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo. Qual pai de família, morador de uma região afastada do centro da cidade, em sã consciência, se apresentaria à autoridade policial e/ou ao juiz, para entregar o morador traficante da sua rua, algoz de um usuário de drogas devedor, o famoso "acerto de contas"?

Diante disso, negar a validade dos testemunhos de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. O mesmo vale para confissão do réu, por exemplo. Não nos encontramos mais nos primórdios do processo penal. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre

elas. Todas são relativas!

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput" do CPP, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisum o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Portanto, claro como a luz solar, a autoria do delito de tráfico de drogas pela corré Bruna.

Quanto à Kailane, a despeito de sua negativa, os elementos a lhe incriminar também são abundantes no processos.

A começar pela própria delação de Bruna, conforme se depreende do seu interrogatório.

Como conceitua GUILHERME DE SOUZA NUCCI: "delatar significa acusar, denunciar ou revelar. Processualmente, somente tem sentido falarmos em delação, quando alguém, admitindo a prática criminosas, revela que outra pessoa também o ajudou de alguma forma. (...) Naturalmente, tem valor probatório, especialmente porque houve admissão de culpa pelo delator".

Mesmo entendimento da jurisprudência:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. (...) Tráfico bem demonstrado em desfavor de ambos. Confissão de LARISSA e delação do corréu. Condenação mantida. (...)". TJSP; Apelação Criminal 1500200-81.2019.8.26.0481; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Epitácio - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020); e

"Apelação Criminal - (...) - Concurso de Agentes - Pleitos defensivos colimando as absolvições dos corréus por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Materialidade e autorias bem caracterizadas - (...) Delação de um dos comparsas que serve como meio seguro de prova - (...)". (TJSP; Apelação Criminal 0005091-14.2018.8.26.0302; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020) (Ênfase minha).

No entanto, não é apenas a palavra de Bruna que lhe incrimina. Afinal, o policial militar declarou que Kailane já era conhecida nos "meios policiais", justamente por

seu envolvimento anterior com o comércio maligno.

Não se olvide ainda, que segundo esse mesmo agente público, a referida acusada foi presa em flagrante juntamente com a adolescente Mariana Carolina, a qual trazia consigo entorpecentes, e que também a delatou em sede policial (fls. 28).

Registre-se, neste ponto, não ser defeso a este Magistrado utilizar elementos informativos produzidos no curso de inquérito policial, desde que corroborados com as provas produzidas em juízo, como neste caso, tal como acima visto.

Na prática, o desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento.

Destarte, a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando preservados os direitos constitucionais das acusadas, o que foi garantido por este Juízo, no acompanhamento de todas as provas produzidas em sede judicial, inclusive que acabaram por confirmar a versão acusatória apresentada em fase inquisitiva.

Nesse sentido caminha a jurisprudência:

“APELAÇÃO – (...) – Validade dos testemunhos policiais como meio de prova, ausentes indícios de que queiram prejudicar o adolescente – Alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal – Inocorrência – Elementos informativos que, quando corroborados por provas produzidas sob as garantias do contraditório, podem constituir a formação da convicção do julgador – Precedentes – Referida norma processual que somente veda a utilização exclusiva dos elementos de informação para justificar a condenação, o que não é o caso dos autos – (...) – Apelação não provida”. (TJSP; Apelação Cível 0001078-47.2018.8.26.0180; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020); e

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO APOIADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não veda, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial. Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do agravante se lastreou em provas produzidas em juízo, notadamente a versão apresentada por uma das vítimas, corroboradas por elementos colhidos na fase policial, não havendo nulidade a ser reconhecida. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ; AgRg no HC 378640/SP; Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro; Órgão julgador: Sexta Turma; Data da publicação: 01/10/2018) (Grifamos).

Assim, encampar o enredo de Kailane, isolado nos autos, seria não só fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego as normas da verdade e do bom senso, diante do farto conjunto probatório contrário à essa ré.

Ademais, Kailane não apresentou uma prova sequer para demonstrar eventual estratégia criado, seja pelos agentes públicos, pela corré Bruna ou pela

adolescente; nem apontou motivo sério que permitisse tal conclusão, logo, não se desincumbiu do seu ônus, a teor do disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS – PRISÃO EM FLAGRANTE EM PONTO DE VENDA E NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO RECHAÇADAS PELAS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL DIANTE DOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ÁLIBI É DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – A QUANTIDADE DE PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Criminal 0001394-33.2016.8.26.0535; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) (Ênfase na reprodução).

Por fim, esclareço ser desnecessário para configuração do crime de tráfico de drogas que o agente seja flagrado em atos de mercancia, bastando a prática de apenas uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, esclarecendo-se que a finalidade mercantil deve ser demonstrada pelas circunstâncias do caso, como nos presentes autos, diante da quantidade de entorpecentes (4.380 pinos plásticos, do tipo eppendorff, contendo cocaína, na casa de Bruna, e 281 pinos plásticos, semelhantes àqueles, com a menor e com a corré Kailane).

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Portanto, é o caso de condenação das rés pelo crime de tráfico de drogas.

Lado outro, com relação ao crime de associação (artigo 35, caput, da Lei em assunto), o destino das acusadas será a absolvição.

Com efeito, de acordo com o conjunto probatório dos autos, entendo não haver prova suficiente para se concluir, com um mínimo de segurança, que as rés estavam associadas, para o comércio ilícito de entorpecentes.

Convém lembrar que não basta para subsumir a conduta em estudo ao tipo do artigo 35, da legislação de drogas, a presença de dois ou mais agentes. É imprescindível que se revele o animus associativo, a estabilidade, permanência e organização do grupo, com funções pré-determinadas entre seus membros, bem como relação de hierarquia entre eles.

Ressalto que, embora os elementos dos autos tenham apontado superficialmente para uma repartição de tarefas, ficando Bruna responsáveis pela guarda das drogas e Kailane pela distribuição no varejo; diante do contraditório e ampla defesa, nada se produziu a demonstrar a estabilidade e permanência, como requer a tipificação do artigo 35, em comento, de modo a distinguir da eventual traficância, comprovada

aqui, conforme acima.

Assim, inexistem elementos a comprovar a "associação" entre elas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34, ambos da Lei 11.343/06, dado que as provas orais se limitaram em comprovar o tráfico aqui reconhecido.

Este Magistrado não ignora as informações trazidas pela própria Bruna em sua autodefesa de que as drogas estavam em sua casa há alguns dias, e que receberia por semana para guardá-las. Contudo, tais elementos são insuficientes para a condenação das acusadas pelo artigo 35, da Lei de drogas, à míngua dos demais requisitos exigidos pelo tipo penal.

Nesse sentido:

"APELAÇÕES - Tráfico de drogas e Associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006) - (...). Crime de Associação para tráfico - Conjunto probatório frágil - Ausência de elementos suficientes que demonstrem a estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os corréus - Absolvição reconhecida, nos termos do art. 386, VII, do CPP - Recurso parcialmente provido". (TJSP; Apelação Criminal 0001600-86.2013.8.26.0459; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pitangueiras - 1ª Vara; Data do Julgamento: 15/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020) (Sublinhado meu).

Não por outro motivo, aliás, o próprio Parquet requereu a absolvição de ambos por tal delito.

Passo à calibragem penal, pelo crime de tráfico, seguindo a ordem da denúncia.

a) KAILANE PEREIRA DO NASCIMENTO:

A ré é primária e de bons antecedentes (fls. 71).

Contudo, cabe ressaltar a extrema reprovabilidade da conduta, à luz da exorbitante quantidade de narcóticos apreendidos (2.157,30 gramas, peso líquido, de "cocaína", distribuída em 4.661 pinos plásticos, do tipo eppendorf), o que indica risco acentuado ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão.

Além disso, observo que a apreensão revela que a venda ilícita de drogas já havia rendido frutos.

Portanto, hei por estabelecer a basilar em 1/3 (um terço) acima do piso legal, ou seja, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na fase intermediária, anoto que a ré, à época dos fatos possuía 18 anos. Logo, presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual diminuo a sanção em 1/6 (um sexto), para 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa. Não existem agravantes.

Na terceira e última fase, reconheço a causa de aumento da pena do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, por conta do envolvimento da menor Mariana com o tráfico realizado pela acusada, tal como fundamentado acima.

Assim, majoro a sanção em 1/6 (um sexto), finalizando-a em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, à míngua de outras causas alteradoras.

Não faz a ré jus ao benefício do tráfico privilegiado, na medida em que as circunstâncias do caso concreto revelaram sua profunda intimidade com o

narcotráfico, apesar de sua condição de primária aos olhos da lei penal.

Com efeito, restou comprovado que Kailane dedicava-se a essa atividade espúria, pois: não comprovou o desenvolvimento de ofício legítimo; ainda que precárias as informações, os policiais militares asseveraram que notícias davam conta do seu envolvimento com a narcotraficância há tempos; a corré Bruna afirmou que Kailane fazia a ligação com o proprietário das drogas e as distribuía regularmente; apreendeu-se em dinheiro sem origem comprovada em sua posse; a desmesurada quantidade das drogas apreendidas, absolutamente inacessível a uma noviça nessa vil empreitada.

Nota-se, portanto, que a quantidade de entorpecentes não é o único elemento a ensejar tal conclusão.

Aliás, como não existe prova direta dessa circunstância, dedicar-se à atividade criminosa, como bem lançado pelo Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, "os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'", é exatamente essas circunstâncias que comprovam a sua dedicação, conforme julgado que assim se encontra a ementa:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitativa. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além

disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada". (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

Outro não é o entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça:

"Tráfico de entorpecentes. (...) Insurgência defensiva em face da pena. Reprimendas irreprocháveis. Impossibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado. Benefício ao qual não fazem jus às acusadas. Dedicção à atividade criminosa. Volume considerável de droga que revela não serem as rés meras aventureiras no ramo da narcotraficância (...) Precedentes do STJ. Negado provimento ao apelo". (TJSP; Apelação Criminal 0002163-92.2017.8.26.0539; Relator: Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 01/02/2020) (Originais sem marcações).

Tal redutora não se destina àquele que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, hipótese destes autos, mas sim, ao agente que age por um impulso esporádico, em caso isolado, incidindo, portanto, em situações específicas e excepcionais, quando evidenciado que o pequeno tráfico se tratou de singelo desvio na vida da acusada.

Registre-se que tal entendimento encontra-se em linha ainda com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já que a quantidade de droga apreendida não é o único elemento a ensejar a não aplicação do § 4º, do artigo em assunto, não se cogitando o proibido bis in idem.

A propósito, em recente julgado:

"PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A

utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença". (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021) (Sublinhado meu).

b) BRUNA DOS SANTOS SIQUEIRA:

A acusada também não possui condenações anteriores (fls. 73/74).

Porém, tal como acima fundamentado, por ocasião da dosimetria da corré Kailane, observadas as diretrizes do artigo 42, da Lei de drogas, tenho que a conduta de Bruna merece maior reprovação, à vista das mesmas circunstâncias judiciais expostas (grande quantidade de entorpecentes e dinheiro), reportando-me, portanto, aos argumentos expendidos acima.

Logo, fixo a mesma pena-base de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na fase intermediária, considerando a sua confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), finalizando-a em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, por não incidirem outras causas modificadoras.

Assiste ao Ministério Público. Não se pode reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 em relação à Bruna, pois não restou comprovado nos autos que sua conduta envolveu ou visou atingir criança ou adolescente, salientando-se que a menor Mariana Carolina afirmou não conhecê-la, em linha com sua fala.

Lado outro, não é o caso de aplicar em seu favor, a benesse do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06), vez que a ré igualmente fazia do comércio ilícito de entorpecentes o seu meio de vida, após ficar desempregada, conforme admitiu em sua autodefesa.

Com efeito, no referido ato, a acusada assumiu que estava há alguns dias guardando os entorpecentes em troca do pagamento de R\$ 200,00 (duzentos reais) por semana, a demonstrar a perenidade da sua atuação em prol do tráfico.

Com relação ao regime inicial de cumprimento das penas, anote-se que o delito de tráfico é equiparado aos crimes hediondos, de acordo com a atual redação do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, não se mostrando razoável a incidência do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda, em que pese não obrigatório o estabelecimento do regime mais gravoso, já que o C. Supremo Tribunal Federal reconheceu, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo citado (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli).

Porém, convém lembrar, na esteira do julgado citado da Suprema Corte, que tal precedente não invalida a discricionariedade judicial, com possibilidade na análise do caso concreto, de fixação do regime fechado quando entendido como sendo o mais

adequado.

No caso dos autos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado para ambas, à vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima expostas, como a quantidade dos entorpecentes, sem prejuízo da apreensão de dinheiro e envolvimento de adolescente, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. (...) Impossível aplicar o redutor, diante das peculiaridades concretas do caso. Quantidade e diversidade de entorpecentes denota envolvimento perene do réu em atividade de tráfico estruturada. Regime fechado adequado à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso improvido”. (TJSP; Apelação Criminal 0007020-71.2018.8.26.0047; Relator: Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 14/02/2020) (Ênfase na reprodução).

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira das acusadas, forte nos artigos 49, § 2º, do Código Penal, e 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

- a) condenar KAILANE PEREIRA DO NASCIMENTO, qualificada nos autos, por violação do tipo penal previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, a uma pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e ao pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, diária mínima;
- b) condenar BRUNA DOS SANTOS SIQUEIRA, qualificada nos autos, por violação do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma pena de 05 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e ao pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, diária mínima; e
- c) absolvê-las da imputação restante que lhes foram irrogadas na denúncia (artigo 35, caput, da Lei 11.343/06) na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de medidas despenalizadoras, à luz do montante de pena aplicado.

No entanto, considerando a primariedade da corré Bruna, bem como seu tempo de prisão preventiva (mais de um ano e dois meses), concedo-lhe o direito de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

O mesmo direito será concedido à corré Kailane, já que após ser agraciada com a liberdade provisória neste feito (fls. 90/95), se fez presente a todos os atos

processuais que se sucederam.

Custas pelas vencidas, observada a gratuidade de justiça, que ora lhes concedo.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado às fls. 151, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder à sua destruição.

Decreto o perdimento da quantia e do celular apreendidos (fls. 11/12) em favor da União. Quanto ao numerário, observo que Kailane não comprovou a sua origem lícita. No que se refere ao aparelho celular, as provas indicaram que o objeto, embora comprado e, em nome de sua avó, era utilizado pela acusada para se comunicar com o real dono das drogas apreendidas, o que faço na forma do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/06. Expeça-se o necessário, com o trânsito em julgado.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Preliminar – Restituição de valor apreendido – Desacolhimento – Caderno processual que indica que o numerário questionado é proveniente da prática do tráfico de drogas – Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do dinheiro apreendido – Perda em favor da união corretamente determinada – Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei n.º 11.343/06 – Preliminar rejeitada. (...) Condenação mantida. (...) – Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500220-88.2021.8.26.0356; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirandópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021) (Ênfase minha).

Fl. 275. Defiro conforme requerido. Providencie a serventia o necessário.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se mandados de prisão e guias de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, conforme disposto nos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado; d) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento dos processos de execução, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA